

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙に対し、丙の日本刀を盗んでくれば高値で買ってやると申し向け、乙が盗んできた日本刀を買い受けた。甲には、窃盗教唆罪及び盗品等有償譲受け罪が成立し、これらは併合罪となる。
2. 甲は、乙が強盗を行うつもりであることを知りながら、乙に模造拳銃1丁を貸し与えたところ、乙は、2店のコンビニエンスストアで、同模造拳銃を使ってそれぞれ強盗を行った。甲には、2個の強盗幫助罪が成立し、これらは併合罪となる。
3. 甲は、乙を殺害する目的で乙が居住する家に侵入し、乙及び偶然その場に居合わせた丙をそれぞれ殺害した。甲には、乙に対する住居侵入罪及び殺人罪が成立し、これらは牽連犯となり、これと丙に対する殺人罪が併合罪となる。
4. 甲は、強盗の目的で、路上を連れ立って歩いていた乙及び丙に対し、包丁の刃先を両名の方に向けながら「お前ら金を出せ。出さないと殺すぞ。」と言って脅迫し、両名からそれぞれ現金を奪った。甲には、2個の強盗罪が成立し、これらは併合罪となる。
5. 甲は、恐喝の手段として乙を監禁し、乙から現金を喝取した。甲には、監禁罪及び恐喝罪が成立し、これらは併合罪となる。

Na194	罪数	正答率
H26-11	正解 1、5 (順不同)	74%

1 正しい

最判昭25.11.10。判例は、本記述と同様の事案において、窃盗教唆罪と盗品等有償譲受け罪は牽連犯とはならず併合罪（45条前段）になるとしている。その理由として、判例は、窃盗教唆と贓物故買（盗品等有償譲受け）との間には通常手段又は結果の関係はないということを挙げている。

2 誤っている

最決昭57.2.17（百選 I 107事件）。判例は、本記述と類似の事案において、「幫助罪は正犯の犯行を幫助することによって成立するものであるから、成立すべき幫助罪の個数については、正犯の罪のそれに従って決定されるもの」とした上で、幫助罪が数個成立する場合に、観念的競合の関係となるか否かについて、「刑法54条1項にいう1個の行為によるものであるか否かについては、幫助犯における行為は幫助犯のした幫助行為そのものにほかならないと解するのが相当であるから、幫助行為それ自体についてこれを見るべきである」としている。よって、本記述の甲には強盗罪の幫助犯が2罪成立することとなる。そして、甲の幫助行為は、乙に模造拳銃1丁を貸し与えたという1個の行為であるから、甲に成立する2個の強盗幫助罪は、観念的競合の関係となる。

3 誤っている

最決昭29.5.27（百選 I 106事件）。判例は、3個の殺人の行為は1個の住居侵入とそれぞれ牽連犯の関係にあり54条1項後段、10条を適用し1罪としてその最も重き罪の刑に従い処断すべきとしている。このように、併合罪となるべき数罪が、その各々と別の一罪とが科刑上一罪となる結果、全体として科刑上一罪として処理される（かすがい現象）。本記述でも、住居侵入罪をかすがいとして、乙に対する殺人罪、丙に対する殺人罪を合わせて全体で科刑上一罪となる。

4 誤っている

54条1項前段。1個の行為が複数の罪名に触れる場合には、観念的競合として、科刑上一罪となる。判例（大判大6.11.9）は、1個の行為で複数人を殺害しようとした行為につき、殺人未遂罪の観念的競合であるとしている。本記述の甲は、乙及び丙に対し、包丁の刃先を向けながら脅迫行為をし、両名から現金を奪っている。この脅迫行為については1個の行為であることから、甲には強盗罪が2罪成立し、これらは観念的競合となる。

5 正しい

最判平17.4.14（百選 I 103事件）。判例は、本記述と同様の事案において、恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても、両罪は、犯罪の通常形態として手段又は結果の関係にあるものとは認められず、牽連犯の関係にはないと解するのが相当であるとして、併合罪として処断した第1審判決を是認した原判決を維持している。